

0000862-93.2013.8.26.0493

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes da Lei de licitações

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.296/1996 E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PARA O RÉU. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10 - Portal do Sol

CEP: 19570-000 - Regente Feijo - SP

Telefone: (18) 3279-1555 - E-mail: regfeijo@tjssp.jus.br

0000862-93.2013.8.26.0493 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000862-93.2013.8.26.0493

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes da Lei de licitações

Autor:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu:

FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO: Em 01/07/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta Comarca de Regente Feijó. Eu, assistente judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, inicialmente em face de:

- FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, vulgo "Chiquinho da CDHU", como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, por cinco vezes, e no artigo 96 da Lei nº 8.666/93, por uma vez, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

- CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMANN como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, por cinco vezes, e no artigo 96 da Lei nº 8.666/93, por uma vez, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

- ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, por três vezes, e no artigo 96 da Lei nº 8.666/93, por uma vez, todos na forma do artigo 69 do Código Penal;

Consta da denúncia que, no decorrer do ano de 2004, na cidade de Taciba, nesta Comarca de Regente Feijó, os denunciados, previamente ajustados e agindo em

concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços para a obtenção de resultado comum, fraudaram, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo das cartas convite nº 08 e 12/2004, sendo a primeira para prestação de serviços de administração de obra de construção de unidades habitacionais, bem como treinamento de mutirantes, em convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e a segunda para aquisição de materiais de construção.

Consta, também, que, no mesmo período, os denunciados fraudaram o caráter competitivo da Concorrência Pública nº 02/2004 realizada para a contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2011 (fl. 1442).

Os réus CARLOS e ROSALY foram citados (fl. 1469) e apresentaram resposta à acusação (fls. 1459/1461, 1478/1482 e 1485/1520).

FRANCISCO foi citado por edital (fl. 1540) e, através de defensora dativa, apresentou resposta à acusação (fl. 1475).

A decisão de fl. 1566 deferiu, em relação ao réu FRANCISCO, a produção antecipada de provas (fls. 1656/1661, 1690/1691).

A decisão de fl. 1693, datada de 19/02/2013, em relação ao réu FRANCISCO, suspendeu o processo, bem como o curso do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, tendo, ademais, sido determinado o desmembramento do Processo inicial, dando origem a esta demanda.

O réu FRANCISCO constituiu defensor e apresentou defesa escrita (fls. 2037/2043 c/c fls. 2050/2051 c/c fl. 2138 (fls. 2146/2148) e fl. 2218).

Foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 2055/2056).

Houve a juntada de prova à fls. 2061.

Durante a instrução, houve a colheita da prova oral, tendo o réu sido interrogado (fls. 2064/2067, 2113 c/c fl. 2173, 2121v/2123, 2126/2127, 2203/2204).

Reproduzida às fls. 2070/2084 a sentença proferida no Processo nº 0002053-86.2007.8.26.0493 relativa aos fatos em tela em relação aos corréus CARLOS EDUARDO SAMPAIO KAUFFMAN e ROSALY SYLVIA RAMALHO SAMPAIO.

Em alegações finais, por memoriais, o Ministério Público postulou a procedência da acusação (fls. 2222/2244).

A defesa, por sua vez, suscitou preliminares de nulidade. No mérito, advogou tese absolutória (fls. 2252/2330).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, verifica-se ser caso de aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383, caput, do Código de Processo Penal.

Os fatos descritos na denúncia descrevem que o réu FRANCISCO fraudou, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório nº 08/2004, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto de tal licitação. Ademais, a incoativa descreve que FRANCISCO fraudou, em prejuízo da Fazenda Pública, os certames licitatórios nº. 12/2004 e 02/2004, destinados à aquisição de material para construção, alterando a substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida.

Logo, aplicando-se o instituto da emendatio libelli, o réu FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA, vulgo "Chiquinho da CDHU", deve ser julgado sob a acusação de estar incurso nas penas do artigo 96, inciso IV, por duas vezes, da Lei nº 8.666/93, c.c. artigo 71, caput, do Código Penal, e no artigo 90 da Lei nº 8666/93, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

É bem de ver que a emendatio libelli não importa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos e não da capitulação realizada na denúncia.

Prosseguindo, anote-se que os artigos 90 e 96, da Lei nº 8.666/93, foram revogados pela Lei nº 14.133/2021.

Ocorre que a supressão dos referidos dispositivos legais não pode ser entendida como "abolitio criminis", sendo, em verdade, o cenário de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, uma vez que as condutas relativas a tais normas

constituem os tipos penais dos artigos 337-F e 337-L, do Código Penal, todavia, com penas maiores do que as previstas nos artigos revogados.

Dessa maneira, sendo a nova legislação mais prejudicial ao réu, deve a legislação anterior - artigos 90 e 96, da Lei nº 8.666/93 - ainda ser aplicada, em virtude da ultratividade da norma penal mais benéfica.

No que tange à arguição de ilegitimidade passiva, atipicidade da conduta, ausência de elemento do tipo penal, assim como que a vítima seria a CDHU que não se confunde com a Fazenda Pública, verifica-se, em verdade, que tais questões se referem ao *meritum causae*, o que será dirimido a seguir.

Por sua vez, no que cerne à preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de mídia referente ao "pen drive" apreendido, assim como de ter havido cerceamento de defesa e afronta aos artigos 155, 157 e 158-A do Código de Processo Penal, o inconformismo não colhe foro de prosperidade.

Observa-se que tal insurgência resta possibilitada de apresentação desde a fase inquisitorial, assim como quando do recebimento da denúncia e, ainda, quando da apresentação da defesa escrita/resposta à acusação, passível, aliás, de esgotamento nas vias recursais após a respectiva negativa em tais momentos, o que, in casu, não se verifica.

Ou seja, a defesa propositadamente deixou de esgotar tempestivamente a sobredita matéria, objetivando somente agora, em sede de alegações finais, com nítido intuito procrastinatório a (re)apreciação da referida questão, o que não merece prosperar.

Em situações análogas, a propósito, já se decidiu:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CORRUPÇÃO ATIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OPERAÇÃO ASTRINGERE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS PRODUZIDAS COM AS MEDIDAS CONSTRITIVAS CAUTELARES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ESCUTA AMBIENTAL. NULIDADE NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR NAS FASES DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DEFESA PRELIMINAR. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE AS PROVAS FOSSEM REUNIDAS E DADO ACESSO LIVRE DAS DEFESAS. DEFENSORES DOS RÉUS. DEBANDADA DA ASSENTADA. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA DOS CAUSÍDICOS CONSTITUÍDOS EM ATUAR. TUMULTO PROCESSUAL. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA O ATO. PERMANÊNCIA DA DEFESA CONSTITUÍDA NA ATUAÇÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. ESCORREITO TRÂMITE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA: PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. JULGADOR ATUANTE NO INQUÉRITO. PREVENÇÃO QUANTO AO PROCESSO CRIMINAL. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo consignado no acórdão proferido no julgamento do recebimento da denúncia, bem assim informado pelo Juízo Singular, as defesas dos réus tiveram acesso ao material colhido com a investigação, notadamente aos áudios registrados com as interceptações telefônicas e escutas ambientais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, ainda mais quando se constata que nenhum dos réus veiculou tal constrangimento em sede de defesa preliminar ou de defesa prévia. 2. Uma vez não tendo as mídias correspondentes ao resultado das medidas constritivas cautelares acompanhado os autos no momento da remessa da ação penal, do Tribunal para o Juízo Singular, isso não impõe considerar, por si só, a existência de cerceamento de defesa, sobretudo diante da determinação da magistrada condutora do feito para que as provas fossem novamente reunidas antes do término da instrução, a fim de conferir livre e irrestrito acesso à defesa dos réus. 3. A designação de defensor público apenas para atuar em determinada assentada, na qual restaram ouvidas as testemunhas, deu-se após a injustificada recalcitrância dos causídicos constituídos em atuar na audiência, não obstante estivessem inicialmente presentes, tendo apresentado pleitos outros - que foram indeferidos pelo julgador -, e teve como objetivo evitar o tumulto processual causado pelos advogados mandatários, que permaneceram atuando para os subseqüentes atos processuais, visto que não houve renúncia, inexistindo falar, na espécie, em violação do princípio da ampla defesa, a sobressair, portanto, o correito trâmite processual - artigo 265, § 2.º, do Código de Processo Penal. 4. A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium

(proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um comportamento sinuoso dos advogados constituídos, não dado é reconhecer-se a nulidade. 5. A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre corréus defendidos pelo mesmo causídico, apresentação de teses conflitantes, sendo que, in casu, das razões do writ consta apenas a menção de que os réus tiveram o mesmo defensor, sem, analiticamente, elucidar-se o prejuízo que tal circunstância, per se, neutra, poderia ter acarretado. 6. Ademais, não se logrou êxito na comprovação do prejuízo decorrente das vertidas alegações, tendo somente sido suscitadas genericamente as matérias, sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 7. "A distribuição da ação penal por prevenção ao relator que proferiu decisão no inquérito (RISTJ, art. 71) não configura hipótese de impedimento do art. 252, II e III do Código de Processo Penal" (EDcl na APn 300/ES, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2007, DJ 23/10/2007, p. 222). 8. Ordem denegada. (STJ, HC 369.759/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016 - destacou-se)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.296/1996 E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO PARA O RÉU. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO. ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROVA EMPRESTADA E PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos. Ainda que assim não fosse, a interposição do agravo regimental leva ao órgão colegiado o julgamento do recurso especial, afastando qualquer nulidade eventualmente existente. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que não configura nulidade das interceptações a ausência de transcrição integral do conteúdo. O Tribunal de origem concluiu pelo preenchimento das exigências legais e entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. Ademais, no tocante às mídias das gravações telefônicas, a Corte de origem consignou que não houve prejuízo para o réu, pois a defesa teve acesso às transcrições mas "[...] não requereu em nenhum momento acesso integral ao conteúdo das mídias se insurgindo sobre a suposta violação ao contraditório apenas após o encerramento da instrução processual. Além do mais, a defesa não chegou a apontar trechos que teriam sido deliberadamente omitidos ou mesmo falta de fidedignidade da transcrição peitos policiais responsáveis pela feitura do relatório" (fls. 1.539/1.540), tendo sido mantido o acórdão. 3. A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EResp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). In casu, o laudo de constatação da substância entorpecente apreendida (maconha), assinado por perito da Polícia Civil, que embasou a condenação pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da jurisprudência deste Sodalício configura documento válido para a comprovação da materialidade delitiva, reforçada pelas gravações telefônicas e depoimentos dos

policiais colhidos em regular instrução. 4. Quanto às provas dos crimes, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o reexame das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Os temas da prova emprestada e pena-base não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo. Carece, assim, o presente apelo, no ponto, do requisito indispensável do prequestionamento, incidindo, na hipótese, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1629624/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020 - destacou-se).

Nem se alegue, in casu, que os documentos obtidos na fase inquisitiva não poderiam ser utilizados como provas nestes autos, porque não teriam sido produzidos em Juízo. Ora, encartada a prova documental neste feito, dessa maneira, por conseguinte, passou ela a ter aptidão de ser examinada sob o crivo do contraditório e a ser passível de ser tempestivamente rechaçada e se a defesa se manteve inerte, inviável agora cogitar-se em nulidade.

Leciona Renato Marcão que: "Ainda que determinadas provas não sejam objeto de questionamento no momento de sua colheita, contemporaneamente à sua produção, ficam expostas ao contraditório diferido, que necessariamente se verificará ao tempo da persecução penal em juízo, quando então caberá à defesa argumentar e provar eventual ilegalidade na sua produção e consequente desvalia frente ao ordenamento."

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na escola, trata-se de prova documental não repetível. 2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1704610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020 - destacou-se)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AMPARADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CABIMENTO. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a literalidade do disposto no art. 155, caput, do CPP, há uma ressalva para o cabimento de condenação exclusivamente com base em elemento não repetível colhido na fase administrativa. Precedentes. 1.1. No presente caso, considerando que o procedimento administrativo fiscal é prova documental não repetível que admite o contraditório diferido para refutá-la, a condenação com base exclusivamente nele é cabível. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1404660/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019) (destacou-se)

Outrossim, somente neste momento processual quer a defesa levar adiante tese de quebra da cadeia de custódia da prova relativa ao conteúdo do "pen drive", devendo ser salientado que já foi reconhecido que mencionado dispositivo foi apreendido em regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo sido elaborado o regular auto de extração, passando, a partir de então, a ser prova documental, que, frise-se, não teve no caso em tela a sua impugnação, tampouco, o esgotamento dessa no momento oportuno, não havendo qualquer indício que possa retirar a confiabilidade da referida prova, que goza de presunção de idoneidade, o que corrobora para o

insucesso da questionada insurgência.

Igualmente, não colhem foros de prosperidade as alegações de inépcia da denúncia/descrição genérica dos fatos, pois verifica-se ter havido a precisa descrição da atuação de cada acusado na empreitada criminosa em análise. Se não bastasse, é cediço que, nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que se faz presente na hipótese em testilha.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA GERAL. POSSIBILIDADE. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO COMPROVADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento desta Corte, é possível o oferecimento de denúncia geral quando uma mesma conduta é imputada a todos os acusados e, apesar da aparente unidade de designios, não há como pormenorizar a atuação de cada um dos agentes na prática delitiva. No caso, a denúncia não é inepta, mas apenas possui caráter geral, e tampouco prescinde de um lastro mínimo probatório capaz de justificar o processo criminal. Precedentes. 2. A denúncia descreve a conduta delituosa em tese praticada pelo acusado (determinação de abertura dos envelopes mesmo diante de flagrante ilegalidade), relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes, nomeadamente o modus operandi do delito (alteração repentina de cláusula significativa do edital, a cinco dias do certame, com o fim de impossibilitar a concorrência) e a vantagem indevida supostamente visada pelos agentes (emissão de empenho no valor total de R\$ 2.338.226,94 à empresa beneficiada), bem assim os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal. 3. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese. 4. Não se pode, pois, de antemão, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal. 5. Recurso desprovido.” (Processo RHC 36651 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2013/0093295-9, Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 25/11/2013).

Vislumbra-se que o cenário dos autos é de imputação ao acusado de que atuou em coletividade com outras pessoas, já tendo, em relação a essas / corréus, sido proferidos sentença e v. acórdão no Processo nº 0002053-86.2007.8.26.0493, sem que se tenha verificado nulidade na exordial acusatória.

Oportuno aduzir que a defesa, às fls. 2150/2169, já pleiteou, em síntese, o reconhecimento de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e do contraditório, por ausência de documentos essenciais à compreensão da imputação, bem como pelas omissões na realização do laudo pericial ou, subsidiariamente, sobrestamento do feito até juntada das referidas mídias; o desentranhamento do laudo pericial de fls. 1016/1038 e elaboração de nova perícia; a intimação do Perito Criminal responsável pela elaboração do laudo; a disponibilização da documentação e conjunto probatório utilizado pelo Sr. Perito; a declaração de ilicitude da busca e apreensão, cuja decisão de fls. 2219/2220, que indeferiu a pretensão, já consignou que tal pedido não buscava esclarecer fatos novos, tendo sido ressaltado que, acerca da produção de perícia técnica, já tinha havido indeferimento de idêntica pretensão formulada na defesa prévia (fls. 2055/2056), tendo a defesa sido intimada da respectiva decisão (fl. 2062), datada de 11/03/2019, nada tendo sido impugnado, tratando-se, em verdade, de pedidos “... meramente protelatórios, visto que são ponto de insurgência cujos momentos processuais aptos para o debate já decorreram, não sendo aceitável que na atual fase processual a defesa queira rediscutir assuntos que já foram debatidos e

decididos nos autos, ou, sequer, suscitados e contestados na fase oportuna. ... ". Invoca-se, ainda em sede de análise de matérias preliminares, o brocado "pas de nullité sans grief", princípio geral norteador das nulidades em Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual, se ausente comprovação de prejuízo, cenário dos autos.

No mais, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pela documentação coligida ao processo, mais especificamente o teor dos procedimentos licitatórios (fls. 23/128, 129/223, 224/463), objetos de fraude, bem como pela sindicância da CDHU (fls. 889/918), ainda, pelo laudo pericial acostado às fls. 1016/1038, o qual apontou a baixa qualidade e o desacordo com as licitações instauradas, em relação aos materiais fornecidos pela empresa inidônea, a quem foram adjudicados os objetos dos certames licitatórios nº 12/2004 e 02/2004, causando prejuízo à Fazenda Pública. Sobremais, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório também corroborou a prática delitiva em liça pelo acusado.

A testemunha Humberto Emmanuel Schmidt aduziu que "Chiquinho da CDHU" era dono de uma empresa, mas que, na verdade, tinha várias empresas, estas, por sua vez, em nome de "laranjas", que eram utilizadas para fraudar licitações instauradas pelos municípios. Esclareceu que a CDHU repassava verba para os municípios, os quais contratavam empresas para o fornecimento de assessoria técnica e materiais para construção. Acerca de Carlos Eduardo Kauffmann, esclareceu que este era responsável por levar aos prefeitos o chamado "kit licitação", que consistia em fornecer-lhes a minuta digital, planilhas relativas à licitação a ser instaurada pelos mesmos, enfim, um modelo de licitação praticamente finalizado, o qual, porém, acabava por beneficiar as empresas do grupo fraudador do qual fazia parte. Assim, embora empresas distintas se sagrassem vencedoras do certame licitatório, todas pertenciam ao mesmo grupo. Confirmou que dentre o material apreendido durante as investigações, havia um "pen-drive" com pastas de arquivos, cujos nomes eram os dos municípios fraudados. Salientou que foi verificado que o grupo construiu imóveis abaixo do padrão de qualidade estabelecido pela CDHU, tendo o lucro dos fraudadores se dado em razão de terem sido contratados e terem recebido para construir casas num determinado padrão de qualidade, tendo, porém, sido construídos imóveis com padrão de qualidade inferior. Apontou como deficiências nas obras, as quais consignou que tiveram que ser refeitas às custas da CDHU, a cobertura das casas, em que foi utilizado eucalipto "in natura", material que não era aceito pela CDHU, utilização de caixa d'água de fibrocimento, também apontado como material não aceito pela CDHU e, indicando, como maior deficiência, as esquadilhas metálicas utilizadas (portas e janelas) nos imóveis. Informou que os prejuízos à Fazenda Pública, quanto às obras fraudadas na região, foram em torno de quinze a vinte milhões de reais (fl. 1691).

A testemunha Orlando Monteiro do Amaral Júnior disse em juízo que, embora tenha, como Delegado de Polícia, ouvido pessoas acerca dos fatos narrados na denúncia, não se recorda do que aqueles lhe disseram, porquanto a oitava de tais pessoas se deu há razoável tempo pretérito. Todavia, confirmou o teor do relatório por ele, depoente, subscrito (fl. 1660).

A testemunha Cícero Ferreira da Silva Filho relatou ter periciado dois conjuntos habitacionais construídos na cidade de Taciba. Em relação ao conjunto habitacional "Taciba D", declarou que foram constatadas irregularidades atinentes à madeira utilizada, esclarecendo ter sido empregada espécie diversa (eucalipto) da prevista em contrato (madeira de lei, por exemplo, peroba ou garapeira). Ademais, apontou problemas nas janelas empregadas nas obras, especificando problemas nas esquadilhas metálicas. Confirmou a perícia realizada no sobredito conjunto habitacional (fl. 1661).

A testemunha Nelson Tadashi Yaguinuma nada acrescentou ao apurado nos autos (fl. 1659).

A testemunha de defesa Manoel Felix dos Santos Filho nada esclareceu acerca dos fatos, informando que conhece FRANCISCO e que desconhece algo que o desabone, declarando que nunca trabalharam juntos, sendo que somente eram amigos. Que desconhece se FRANCISCO tinha empresa (fl. 2066).

Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio, ao ser interrogada no Processo nº 0002053-86.2007.8.26.0493, negou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Confirmou ser mãe do réu Carlos Eduardo. Confirmou ser proprietária da empresa de material de construção Rosaly Sylvia Ramalho Sampaio ME. Admitiu que sua empresa participava de licitações, porém, não soube informar de quais certames participou. Afirmou que seu filho não tinha nenhuma participação na sobredita empresa (fl. 2076). Carlos Eduardo Sampaio Kauffman, em seu interrogatório no Processo nº 0002053-86.2007.8.26.0493, negou a acusação que lhe foi feita. Negou ter participado de procedimentos licitatórios. Declarou que atuava como advogado trabalhista para as empresas de Francisco. Afirmou que trabalhava para as empresas FT Construções e Comércio Tarabai LTDA e Tibet Comércio e Construções, as quais afirmou serem de responsabilidade de Francisco Emílio de Oliveira. Negou ter agido como administrador da empresa FT Construções. Disse que desconhece o "pen-drive" mencionado nos autos. Declarou que o referido "pen-drive", quando da abertura do saco lacrado em que estavam objetos apreendidos em sua residência, foi aquele retirado do bolso de um dos Delegados de Polícia. Negou ser o proprietário do citado "pen-drive", bem como alegou desconhecer o seu conteúdo. Consignou que, embora a empresa FT estivesse no nome da esposa de Francisco, era administrada pelo próprio Francisco. Desconhece a atuação da sua genitora, Rosaly, em procedimentos licitatórios (fl. 2076).

A testemunha de defesa Adilson Manoel dos Santos declarou que trabalhou na FT Construção e que faziam muitas obras. Narrou que o trabalho era feito em sistema de mutirão, juntamente com os interessados nas casas populares e a FT administrava as obras. Que controlava as horas trabalhadas pelos mutirantes, ou pelas pessoas por eles/mutirantes contratadas ou indicadas, sendo ensinados "alguns pontos para o pessoal". A respeito do material utilizado nas obras, esclareceu que quem o recebia era o chefe de obras e os próprios mutirantes, sendo que estes eram treinados para receber e armazenar os materiais que chegavam. Quanto à madeira utilizada, na maioria das vezes, não dava tempo para que fosse armazenada, porque já havia uma frente de serviço esperando para utilizá-la. Que quando havia a necessidade de armazenamento, essa não era colocada diretamente no chão. Informou que acredita ter participado da conferência da entrega da obra pela CDHU ou pela empresa LBR, porque havia muitas entregas de obras. Esclareceu que somente há a entrega do imóvel quando este está pronto para ser habitado, o que era norma da CDHU. Que após a entrega, ficava uma pessoa no local por cerca de 30 dias para dar assistência, como o mestre de obras. Em relação a FRANCISCO, afirmou que o conheceu entre os anos de 2013 ou 2014 e que se tratava de uma pessoa com vida simples, salientando que os mutirantes não o criticavam, tratando-se de um "cidadão normal". Aduziu que não chegavam reclamações das obras diretamente para ele e que, indiretamente, algumas vezes ouvia reclamação do morador ao mestre de obras, em relação a ajuste de telhas, por exemplo. Que durante as obras, não ouviu comentários de que FRANCISCO estivesse envolvido em fraude de licitações de Prefeituras, o que somente ficou sabendo posteriormente, durante a investigação (fl. 2126).

Em seu interrogatório judicial, FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA declarou que participou e ganhou uma concorrência pública na Prefeitura de Taciba para realizar a administração técnica de uma construção - autoconstrução - de casas populares. Aduziu que a realização das obras era feita pelos próprios mutuários, que eram treinados, sendo este seu trabalho, além da aquisição dos materiais utilizados. Relatou que a fiscalização era realizada pela CDHU e por uma empresa gerenciadora que mensalmente verificavam os serviços efetivamente executados - se estavam de acordo com o padrão de autoconstrução, que não era igual ao de empreitada, diante da mão de obra utilizada, que não era habilitada, mas treinada, pelo chefe de equipe e pelo mestre de obras. Que toda semana os mestres de obras da CDHU e das empresas gerenciadoras, como a LBR, realizavam a medição das obras e verificavam se o serviço estava correto. Que, depois, a cada 30 dias verificavam os serviços prontos - se estavam corretos e que, então, efetuavam o pagamento para a Prefeitura, que lhe repassava o valor de administração técnica contratado com ele. Mencionou que, se não existisse serviço feito, não se pagava nada e que se estivesse tudo correto, era feito um atestado de conformidade e, ainda, caso não



estivesse a obra de acordo com as normas técnicas da CDHU, o serviço tinha que ser feito e que o material tinha que ser por ele repostado. Que acredita que a obra durou cerca de 10 a 12 meses e que, ao final, era feito um check list, vindo uma equipe da CDHU de outra regional para verificar se as casas estavam corretas, se havia algum defeito, por exemplo, uma janela amassada, que tinha que ser trocada. Que se fazia a entrega provisória da obra e que, passados 60 dias, fazia-se a entrega definitiva, chamando os mutuários para o sorteio das casas. Afirmou que na obra de Taciba não houve nenhum apontamento da Prefeitura ou da CDHU de que não haviam sido seguidas as regras impostas. Disse que a entrega da obra se deu mais ou menos no ano de 2005 e que, depois, "aconteceu tudo isso aí". Pontuou que houve "uma interpretação errada das coisas", esclarecendo que cumpriu todo o contrato e que fez tudo da forma que era para ser feito. Confirmou que na época da licitação era proprietário da empresa FT Construções, que está em nome de sua esposa, mas que era administrada por ele. Que não se recorda de outras empresas que participaram da licitação de Taciba. Que, também, não se recorda de ter ido para Taciba, na sede da Prefeitura, e participado da licitação, porque já fazia 16 anos. Esclareceu que a CDHU tinha um convênio com a Prefeitura e que era a responsável pela fiscalização da obra, como medições e conferência de materiais, através de empresas gerenciadoras. Negou que nas fiscalizações tivesse sido apontado algum problema com "materiais inferiores" utilizados e que, somente no ano de 2007, com a operação "Pomar" houve o levantamento do problema. Disse que "o grande problema dessa confusão de materiais" foi que a Prefeitura comprava o material e as especificações tinham que ser de acordo com a Prefeitura, mas que no laudo técnico realizado nos autos não foram levadas em consideração as especificações da Prefeitura, mas sim as apontadas pela CDHU, inclusive, de serviços, que não era o caso, porque eram feitos pelos mutuários e atestados pela CDHU. Exemplificou que se há especificação da Prefeitura na licitação de uma torneira de plástico, o técnico não pode exigir que fosse de ferro, porque não era a especificação do edital, sendo que teria que se verificar o padrão imposto na licitação. Que no caso da caixa d'água, a Prefeitura compra uma caixa de fibra de cimento, "a CDHU vem e diz que a caixa d'água tem que ser de fibra de vidro, mas foi comprada a caixa que a Prefeitura especificou". Que acredita que a divergência está nesse ponto, consignando que, inclusive, ganhou um Processo em São Paulo no qual foi verificada tal questão através da documentação. Em relação à madeira, foi apontado que se trata de eucalipto, mas não acredita que a pessoa possa apenas olhar a madeira e apontar qual se trata. Aduziu que na licitação não havia especificação do tipo de madeira, mas sim da resistência, o que não foi observado pelo perito. Assegurou que as obras foram realizadas de acordo com o projeto apresentado pela Prefeitura, não como a CDHU apontou, porque não foi contratado por esta. Ademais, informou que a CDHU realizou as fiscalizações mensais e apresentou os atestados de conformidade com o projeto. Não soube explicar o motivo pelo qual foi acusado. Disse que a obra de Taciba foi finalizada entre 2004 e 2005 e que foi investigado somente em 2007. Mencionou que, na época dos fatos, não era formalmente inserido em nenhuma pessoa jurídica e que administrava a FT, sendo registrado como engenheiro civil responsável, mas que sua esposa era a proprietária da referida empresa. Assegurou que não era formalmente sócio ou que detinha voz de comando em relação às demais empresas apontadas nos autos. Declarou que a FT não estava em seu nome, porque até o ano 2000 tinha outra empresa de construção ("Tibet") em São Paulo, de subempreitada, porque não conseguia entrar diretamente nas concorrências públicas e que, então, uma parte do trabalho era passada para sua empresa por empresas maiores e que essas empresas "quebraram" e não pagaram a sua parte, vindo, então, a também "quebrar". Que, por isso, não teve condições de colocar a empresa FT em seu nome. Em relação à acusação de manipulação de preços, diante da influência política que tinha para ajudar na elaboração das planilhas e manipular o preço, negou veementemente. Afirmou que não participou da elaboração dos papéis dos editais, no sentido de inserir exigências que somente ele poderia cumprir. Esclareceu que na época em que ocorreram os fatos em Taciba, CARLOS EDUARDO não trabalhava na FT, informando que ele ingressou no fim de 2005, como administrador formal, e que em 2006 começou a responder por fatos correlatos aos apurados. Ao ser questionado se realizou negócio de aquisição de materiais na

empresa de ROSALY, mãe de CARLOS EDUARDO, declarou que no serviço que prestava não comprava material e sim a própria Prefeitura, através de edital, nesse caso, por tomada de preço. Assegurou que não obteve qualquer remuneração em relação ao lucro referente à venda de materiais que ROSALY realizou para as obras em questão. Detalhou que a fiscalização da obra é feita pela CDHU, mediante o convênio realizado com a Prefeitura, e que havia a presença da CDHU ou da empresa gerenciadora, o que era semanal. Negou que tenha se aliado aos engenheiros da CDHU no sentido de confirmarem que a obra estava sendo realizada da maneira correta, mesmo quando não estava. Declarou que havia 18 fiscais diferentes que passavam nas obras, entre mestres de obras e engenheiros e que, se tivesse corrompido ou mancomunado, isso teria que ser feito com 18 pessoas, além dos chefes, inclusive com funcionários da CDHU, na capital. Ao ser questionado se o material apontado como inferior teria sido aprovado na época pelo fiscal da obra, disse que não tinha relação com os materiais adquiridos pela Prefeitura de Taciba, pois não era quem recebia e sim a Prefeitura. Disse que após ser preso não tem mais qualquer tipo de renda de atividade empresarial e que seu patrimônio foi confiscado, em razão de Processos Trabalhistas movidos contra ele. Nega que tenha patrimônio registrado em nome de terceiros. Asseverou que cada imóvel de autoconstrução, na época, custaria cerca de R\$ 10.000,00 e com tal custo de obra não tinha como ocorrer superfaturamento, além de pagamento de propina para a CDHU, Município, pessoas terceirizadas fiscalizadoras. Aduziu que tinha que entregar entre 700 a 800 casas, por ano, para poder lucrar e a empresa crescer. Em relação às empresas AJ e RJ Engenharia e Comércio de Serviços LTDA e a CONSTRUTEC SR LTDA, que participaram do convite 08/2004, que tratava de gerenciamento de obras e treinamento de mutuários, não sabe se foram investigadas ou mesmo denunciadas criminalmente por fraudes em processos de licitação. No que tange às empresas ROSALY SAMPAIO, Portal Comércio de Materiais e Pedro Pereira de Taciba, que se sagraram vencedoras no Convite 12/2004, para a aquisição de materiais para construção, declarou que conhece ROSALY, que é mãe do CARLOS EDUARDO, mas que não sabe se foram investigadas ou processadas por fraude em licitações. Que, da mesma forma, não tem conhecimento se as empresas vencedoras do certame 02/2004, para a aquisição de materiais de construção, tiveram problemas correlatos. Confirmou que, segundo o convênio, a CDHU permitia que a Prefeitura realizasse os projetos e memoriais descritivos. Quando questionado se a CDHU interferia nas licitações realizadas pela Prefeitura, declarou que a Prefeitura é sempre soberana nas suas licitações e decisões. Em relação à qualidade e quantidade dos materiais empregados na obra, aduziu que seguiu as estipulações da Prefeitura e não as da CDHU, porque "o projeto é da Prefeitura". Asseverou que na mesma época nunca foram detectados vícios ou defeitos na realização das obras que ensejassem ressarcimento por ele para a Prefeitura. Por fim, disse que a obra foi entregue e paga pela CDHU (fl. 2203).

Pois bem.

Após a dilação probatória, não se vislumbra elementos suficientes para concluir que efetivamente o réu FRANCISCO fraudou, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório nº. 08/2004, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto de tal licitação.

Lado outro, evidenciado que FRANCISCO fraudou, em prejuízo da Fazenda Pública / erário, os certames licitatórios nº. 12/2004 e 02/2004, destinados à aquisição de material para construção, alterando a substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, de modo que, com isso, praticou o crime do artigo 96, inciso IV, por duas vezes, da Lei nº 8.666/93, c.c. artigo 71, caput, do Código Penal. Insta consignar que "licitação", segundo a doutrina, dentre vários conceitos, se trata de um "procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício de sua função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 19ªed., ed. Atlas, pag. 348).

Tal procedimento administrativo além de seguir as regras estipuladas na legislação,

é norteado por princípios, alguns dos quais expressos em lei, os quais definem os lineamentos em que se deve situar o procedimento.

Nessa toada, são princípios básicos do procedimento licitatório, conforme o artigo 3º da Lei Federal nº 8666/93: (a) Princípio da legalidade, (b) da impessoalidade, (c) da moralidade, (d) da igualdade, (e) da publicidade, (f) da probidade administrativa, (g) da vinculação ao instrumento convocatório e, finalmente (h) do julgamento objetivo.

Além dos princípios básicos que regem a disciplina legislativa da licitação, foram previstos outros que, de uma forma ou de outra, guardam conexão com aqueles.

Deveras, o indicado dispositivo legal, após mencionar os princípios básicos da licitação, referiu-se aos princípios correlatos. São, deste modo, correlatos aqueles princípios que advêm dos princípios básicos e que com eles apresentam correlação em virtude da matéria que abordam. Tais princípios estão dispersos na legislação disciplinadora do procedimento licitatório.

Podem ser lembrados, nesse ponto, os princípios correlatos da (a) competitividade, (b) da indistinação, (c) da inalterabilidade do edital, (d) do formalismo procedimental, (e) da vedação à oferta de vantagens e (f) da obrigatoriedade de realização de licitação.

Merece especial destaque, neste processo, o princípio da competitividade.

Referido princípio é correlato ao Princípio da Igualdade e reza que a Administração não pode adotar medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação.

Ora, se é defeso à Administração Pública prejudicar o caráter competitivo da licitação, pois tornaria o procedimento inócuo e prejudicial ao interesse público, mais grave ainda é a conduta de participante da licitação que acaba por prejudicar a competição entre os licitantes.

E, em virtude da enorme gravidade dessa conduta, o legislador optou por bem tipificá-la como crime, descrevendo-a no artigo 90 da Lei nº 8666/93: "Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação".

Pela leitura do sobredito dispositivo legal, denota-se que o agente pratica a conduta de fraudar o caráter competitivo do processo licitatório com a especial finalidade de obter, para o próprio agente ou para terceiro, vantagem daquele ato por qualquer mecanismo.

No caso em tela, o município de Taciba se valeu da modalidade licitatória convite, que é a que comporta menor formalismo, pois se destina a contratações de menor vulto. Nessa modalidade não há edital. As convocações denominam-se "cartas-convite", que são enviadas, no mínimo, a três interessados no ramo a que pertence o objeto do contrato, os quais são livremente escolhidos pelo administrador, entre empresas cadastradas ou não. Recebidos os envelopes com as propostas, segue-se a classificação, adjudicação e homologação, sendo que o procedimento pode ser realizado por servidor designado pela autoridade competente, não sendo obrigatória a comissão de licitação (art. 51, §1º da Lei nº 8666/93).

Extraí-se dos autos que o município de Taciba, mediante convênio celebrado junto à CDHU, instaurou, no ano de 2004, licitação, na modalidade convite, exteriorizada pelas cartas convite nº. 08/2004, 12/2004 e 02/2004, para a construção de 99 (noventa e nove) casas populares, empreendimento denominado "Taciba D".

Segundo a exordial, o réu FRANCISCO e Carlos Eduardo teriam adrede preparado a licitação, para que nela se sagra-se vencedora a empresa F.T. Construções e Comércio, empresa de que eram donos.

De que o réu FRANCISCO era, ao lado de Carlos Eduardo, um dos responsáveis pela empresa FT Construções, não há dúvida. Nesse sentido, a prova testemunhal, notadamente os esclarecimentos de Humberto E. Schmidt; ademais, realizada busca e apreensão na sede da empresa, ali se encontrava Carlos, que se apresentou como seu representante.

A fraude em análise, conforme narra a inicial, teria consistido em fornecimento à Municipalidade de um kit-licitação adrede preparado para favorecer a empresa FT, bem como a habilitação de pessoas jurídicas que pertenceriam, na verdade, ao mesmo

grupo.

A conclusão acerca da ocorrência da fraude, contudo, exigiria demonstração: (a) de que efetivamente FRANCISCO, com o beneplácito de funcionários da Municipalidade, preparou o Convite; (b) de que as empresas participantes da licitação eram mera "fachada", pertencendo, de fato, dentre outra(s) pessoa(s), ao mencionado réu. Conquanto Carlos Eduardo Kauffman, conluído com o réu FRANCISCO, forneceu, para a realização do certame - carta convite nº. 08/2004, a respectiva minuta digital e planilha relacionada à licitação, de maneira a beneficiar empresa pertencente ao grupo fraudador do qual fazia parte, tendo culminado com a contratação da empresa FT Construções LTDA, para a prestação dos serviços de construção civil (fls. 108/110), os autos não abrigam a necessária comparação entre os arquivos hospedados no pendrive apreendido e os documentos oficiais.

Aliás, a aceitação, pela Municipalidade, do kit-licitação fornecido por um dos concorrentes exigiria investigação da conduta de funcionário(s) público(s) municipal(is), o que, no entanto, não houve nesta demanda.

Além disso, lê-se à fl. 105 que o certame teve três propostas, "(...) todas estão aptas a serem comparadas entre si, e a ordem de classificação é a seguinte:" // "AJMJ ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R\$ 148.750,00. FERREIRA E TURRI CONSTRUÇÕES E COMERCIO TARABAI LTDA R\$ 146.520,00. CONSTRUTEC SR R\$ 150.000,00"., constando que as outras empresas concorrentes pertenciam, dentre outras pessoas, ao réu FRANCISCO, tal último fato, porém, sem a necessária prova robusta, havendo apenas, nesse sentido, a vaga menção da testemunha Humberto E. Schmidt de que todas pertenceriam ao mesmo grupo, não tendo, portanto, havido profunda investigação acerca das empresas AJMJ e CONSTRUTEC.

Destarte, no caso destes autos, não é possível fugir à constatação de que a fraude relativa ao Convite nº 8/2004 não encontra segura demonstração nos autos, devendo FRANCISCO, portanto, ser absolvido da imputação da prática do crime do artigo 90, da Lei nº 8666/93, por insuficiência probatória.

Em termos, em relação à questionada prática delitativa, o ônus de provar a materialidade e a autoria compete à acusação, não se podendo presumir a culpabilidade do réu FRANCISCO, mas sim sua inocência, como decorrência lógica do princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu" (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense: 2014).

Assim, estando os autos eivados de dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação. Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que ficou impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito.

Acerca do tema, a propósito, já se pronunciou o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova" (Voto Nº 4.246). Daí porque, "uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório" (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTCRIM 11/118).

Mesma conclusão, porém